

1502479-86.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502479-86.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2291730/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 21031606 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 3567/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3567/2021 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2291730 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS

Data da Audiência:

03/02/2022

Em 3 de fevereiro de 2022 às 14h20, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra.

Fabiola Castilho Soffner. Presente o réu Adriano Cardoso dos Santos, citado em audiência. Presente o Advogado, Dr. Victor Martinelli Paladino (OAB/SP 271.166 ). Presentes as testemunhas comuns Diogo Henrique Silva Melo e Robson Tezolin Ribeiro da Silva. Presentes as testemunhas da defesa Eliane Campos Figueira e Mirian Maria da Silva Timoteo. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, realizou-se a citação do acusado, apenas para regularização dos autos, considerando já haver resposta à acusação (fls. 86/89). A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS, qualificado às fls. 21 e 24, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 21h:12min, na Rua Foz do Iguaçu, nº 300 - Jardim Oratório, nesta cidade de Mauá, trazia consigo, 16 trouxinhas de cannabis sativa, pesando 33,31g, 45 invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 36,9g, consoante auto de apreensão de fls. 12, laudo de constatação de fls. 14/16, e laudo toxicológico definitivo de fls. 46/48, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 58/60). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 35/36). A denúncia foi oferecida (fls. 56/57). O réu foi notificado (fls. 78) e apresentou defesa preliminar (fls. 86/89). A denúncia foi recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 94/98). O réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Diogo Henrique Silva Melo (gravação audiovisual), Robson Tezolin Ribeiro da Silva (gravação audiovisual) Eliane Campos Figueira (gravação audiovisual) e Mirian Maria da Silva Timoteo (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Adriano Cardoso dos Santos (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Diogo Henrique Silva Melo (fls. 5/6) e Robson Tezolin Ribeiro da Silva (fls. 7) e o réu Adriano Cardoso dos Santos (fls. 8). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu, a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Adriano, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4). Auto de exibição e apreensão (fls. 12). Laudo de constatação provisória (fls. 14/16). Receituário médico (fls. 17/19). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 46/48). Laudos de exames de corpo de delito (fls. 129/130 e 131/132). Folha de antecedentes (fls. 28/32 = 63/67 = 107/111) e certidão (fls. 33/34). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do

crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisória (fls. 14/16), receituário médico (fls. 17/19), exame químico toxicológico definitivo (fls. 46/48) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Robson Tezolin Ribeiro da Silva, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu me recordo da ocorrência envolvendo o Adriano; b) estávamos patrulhando pela Rua Foz de Iguaçu o indivíduo nos viu, apertou o passo e o detivemos; c) ele tinha uma pochete que continha cocaína e maconha, não me recordo a quantidade; d) havia dinheiro, mas não me recordo quanto; e) ele tentou empreender fuga, mas o detivemos; f) quando estávamos no D.P., chegou um familiar e ele começou a se debater no guarda-presos, acho que foi assim que ele se machucou; g) não vi ele vender drogas; h) não sei se ele tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes; i) não conhecia o réu (gravação audiovisual e fls. 7). Em juízo, a testemunha Diogo Henrique Silva Melo disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 25 de agosto de 2021 envolvendo o Adriano; b) estávamos em patrulhamento pela via, quando adentramos nessa rua e no término dela estava o Adriano; c) ao nos ver ele ficou nervoso e apertou o passo; d) ele tinha uma pochete que continha drogas; e) depois de chegarmos na Delegacia, depois de chegar parentes dele, acho que a mãe dele, ele começou a bater a cabeça no compartimento de presos; f) não lembro quais as drogas estavam na pochete; g) havia dinheiro, mas não me recordo a quantidade; h) não presenciei ele fazendo a venda de entorpecentes para ninguém; i) foi o primeiro dia que ele estava traficando para uma mulher chamada Gisele; j) não vi o Adriano vender; k) não me recordo as drogas que haviam com o réu, porque isto é costumeiro; l) não conhecia o réu antes dos fatos (gravação audiovisual e fls. 5/6). A testemunha Eliane Campos Figueira, judicialmente, disse que: a) conheço o Adriano desde a infância e não tenho conhecimento dele com práticas criminosas; b) não tenho conhecimento de ele ter envolvimento com facções criminosas; c) não sei onde ele trabalha, mas vejo ele vir do emprego (gravação audiovisual). A testemunha Mirian Maria da Silva Timóteo, em juízo, disse que: a) eu sou vizinha do Adriano; b) conheço ele entre nove e dez anos; c) não tenho conhecimento de ele estar envolvido com facção ou organização criminosa; d) ele faz bico de mudança de construção; e) ele tem uma boa conduta; f) para mim ele sustenta com o seu trabalho (gravação audiovisual). Por fim, o réu Adriano Cardoso dos Santos, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu estava com as drogas; b) eu peguei a pochete para vender, mas não havia vendido; c) eu me arrependi e iria para a casa guardar a pochete, mas a polícia me abordou e não tinha mais o que fazer; d) na pochete havia maconha e cocaína, do mesmo jeito que eu peguei ficou, havia maconha e cocaína e R\$ 48,00; e) peguei a pochete de um rapaz, mas não conheço ele não; f) na pochete havia R\$ 48,00 de troco; g) não sei o nome do rapaz que peguei a pochete; h) em nenhum momento eu falei de Gisele nenhuma; i) foi a primeira e a última vez que peguei a pochete para vender drogas; j) da minha casa aonde eu fui abordado dá 20 minutos; k) não participo de organização criminosa; l) eu sustento a minha casa com os meus filhos; m) não conhecia os policiais (gravação audiovisual e fls. 8). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação provisória (fls. 14/16), receituário médico (fls. 17/19), exame químico toxicológico definitivo (fls. 46/48), como também pelos depoimentos das testemunhas Diogo Henrique Silva Melo (gravação audiovisual e fls. 5/6), Robson Tezolin Ribeiro da Silva (gravação audiovisual e fls. 7), Eliane Campos Figueira (gravação audiovisual) e Mirian Maria da Silva Timóteo (gravação audiovisual), e pela autodefesa do réu Adriano Cardoso dos Santos (gravação audiovisual e fls. 8), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, estavam realizando diligências no local dos fatos, que já era conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, momento em que visualizaram o réu Adriano, que apresentou nervosismo e tentou empreender fuga ao ver os policiais, mas foi detido e, em revista pessoal, foi apreendida uma pochete acondicionada no bolso da blusa do réu, que continha 16 porções de maconha, pesando 33,31g; 45 porções de cocaína, pesando 36,9g; além da quantia de R\$ 54,80. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 tem 18 núcleos e um deles é trazer consigo com a finalidade de venda, que foi o que foi confessado

pelo réu, em suma, o tipo não exige a venda para a sua configuração, sendo que o cometimento de qualquer um dos seus verbos é suficiente para a consumação do crime. O dolo é patente, pois o réu estava em plena via pública com uma pochete com drogas para a venda, conforme confessado por ele (gravação audiovisual); caso contrário, os indivíduos que traficam, ao serem detidos com a droga, alegariam que não pegaram a droga para vender, não efetuaram nenhuma venda e arrependeram-se, safando-se do flagrante nos quais foram surpreendidos (gravação audiovisual). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Adriano Cardoso dos Santos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (16 porções de maconha, pesando 33,31g; 45 porções de cocaína, pesando 36,9g; - fls. 12, 14/16 e 46/48) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 28/32 = 63/67 = 107/111 e 33/34). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Não reduzirei a pena em face da confissão do réu (gravação audiovisual), pois a pena ainda se encontra no seu patamar mínimo, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade as drogas, para fins de redução de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por não haver outro parâmetro de redução, entre 1/6 e 2/3, contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3. Inclusive, no processo nº 1500527-09.2020.8.26.0540, que tramita nesta Vara (fls. 318/325), foi determinado que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz "na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" - (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente (fls. 28/32 = 63/67 = 107/111 e 33/34), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (16 porções de maconha, pesando 33,31g; 45 porções de cocaína, pesando 36,9g; - 12, 14/16 e 46/48), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC

170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempo pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (62 porções de cocaína, contendo 55,63g; 04 pedras de crack, contendo 0,41g; e 63 porções de "maconha", contendo 132,64g) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido." - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 18,7g de cocaína e 348,5g de Cannabis sativa - constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido." - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP,

Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (195,6g maconha, 63,9g de cocaína, 17,1g de crack e mais 118g de cocaína) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar

superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (16 porções de maconha, pesando 33,31g; 45 porções de cocaína, pesando 36,9g; - 12, 14/16 e 46/48), fato concreto que impede a substituição. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 22). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 12), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 12, 14/16 e 46/48). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS (R.G. nº 46.606.957-1 - filho de Daniel Rozeno dos Santos Filho e Vilma dos Santos Cardoso - fls. 21 e 24), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 35/36). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pela defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pelo réu. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem." O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.